

東京高等裁判所第一民事部御中

意 見 書

平成14年9月8日

三木義一(立命館大学教授)
(博士・法学(一橋大学))

一 意見書の趣旨

本意見書は平成一四年(行コ)第一号法人税更正処分等取消請求事件での争点の一つである処分理由の差し替えの可否について、長年税法学を研究・教育してきた者として意見を申し上げるものである。なお、本意見書作成に際して、原審判決、控訴人控訴理由書及び第1～第2準備書面(被告最終準備書面も含む)、被控訴人準備書面(1)～(9)(原審準備書面も含む)等を参照した。

二 前提事実

前提となる事実を整理しておく次のようになる。

原告が平成7年12月27日に同年9月期の法人税の申告をしたところ、被告は平成10年12月18日付で同族会社の行為否認規定(法人税法132条)を適用して、更正処分をおこなった。原告がこれを争い、原審において被告の主張に反駁していたところ、平成13年7月30日に至って、被告は従来主張してきた同族会社の行為否認規定の適用を予備的主張に変え、主位的主張を「無償による資産の譲渡」(法人税法22条2項)に差し替えた。当初の申告期限から実に5年7ヶ月後、更正処分から2年7ヶ月後の理由の差し替えであった。

三 原審の判断

原審はこの点につき、次のような判断をしている。

「本件において、被告は、平成13年5月14日の本件第5回口頭弁論期日の後である同年7月13日当裁判所に対して第6準備書面を提出し、同準備書面の内容を、同年7月30日の本件第6回口頭弁論期日において陳述することにより、初めて前記主位的主張を主張するとともに、従前の主張を予備的主張とし、同期日において本件の弁論が終結に至ったことは当裁判所に顕著な事実であって、被告の主位的主張がされた客観的な時機が本件の弁論終結日に近接した日であることからすれば、当審における審理の最終局面において初めて主位的主張がされたという点において、時機に遅れたものとの嫌いは否めない。しかも、本件処分は、原告に対して新たに100億円を超える多額の税金の納付を命ずる非常に重大な処分であって、原告の状況からするとその死命を制しかねないものであるから、被告としては事前に慎重の上にも慎重を期した上でなすべきものであるにもかかわらず、既に処分から2年半余りが経過した後に、単

なる予備的主張の追加にとどまらず主位的主張自体を全く新たなものに変更する形で新たな主張がされたことは、処分前の検討がはなはだ不十分であったことを示すものであって、そのこと自体は被告の職責に悖るものといわざるを得ない。しかしながら、被告の同主張は、同年3月19日の本件第4回口頭弁論期日における当裁判所の被告に対する求釈明を契機として主張されたものであること、同主張の基礎となる事実関係については従前被告が主張していた法132条の適用に関する主張に包含されるものであって、法律構成に関する新たな主張であること、したがって、本件においては、新たな主張がされたために新たな証拠調べを必要とするものではなかったこと、これに対して原告が速やかに対応したことによって、結果的にみても、上記のとおり被告の主位的主張の記載された準備書面が陳述された本件第6回口頭弁論期日において本件の弁論が終結されており、原告代理人らに多大の負担をかけたことはともかくとして、本件訴訟の進行を遅延させるには至らなかったことの各事実も当裁判所に顕著な事実であり、これらの事情にかんがみれば、被告の主位的主張については、民事訴訟法157条1項が時機に遅れた攻撃防御方法の却下の要件として定める『これにより訴訟の完結を遅延させることとなる』ものとは認められないというべきである。」（原審判決10～11頁）

このように原審は時期に遅れた攻撃防御の問題として処理し、問題点を指摘したものの理由の差し替えの自体は認めている。これは、判決主文で原告の請求を認容していることと、自己の求釈明に起因して変更されたことを配慮しての判断であろう。

四 控訴人の主張

控訴人はこの点につき、明確に陳述していないようであるが、控訴理由書の次の記述がこの問題に対応しているように思われる。

「なお、原判決は、控訴人が訴訟の段階に至って法22条2項による課税の主張を追加し、これを主位的主張としたことをとらえて、本件各処分が不十分な検討に基づく過酷な処分であるとする。しかしながら、課税処分取消訴訟においては、一般にいわゆる『総額主義』が採用されており、課税処分は、これによって確定された税額が総額において租税実体法によって客観的に定まっている税額を超えない限り、適法であると解されている（泉徳治ほか「租税訴訟の審理について」司法研究報告書第36輯第2号78ページ、最高裁昭和49年4月18日第一小法廷判決・訟務月報20巻11号17

5ページ)。そして、本件では、法22条2項の『取引』に当たると解すれば、前記2のとおりに、本件各処分は適法であるし、仮にこれが法22条2項の『取引』に当たらないものと解しても、…法132条による課税として本件各処分は適法であるから、結論において相違はない。そして、22条2項による課税の主張は、法132条による課税の主張に包含される関係にあり、控訴人は、本件増資による資産価値の移転が課税対象となることを、41年判決を示して原審の当初の段階から主張していたのである。」(平成14年1月16日付け控訴理由書58頁)

しかし、総額主義の立場が基本的に採用されているとはいっても、そのことから直ちに被告主張のような結論になるわけではない。以下そのことを具体的に検証してみよう。

五 申告納税制度と総額主義

実務上総額主義的に運用されているとはいっても、学説の多くは争点主義の方に合理性を認めていることにまず留意すべきであり、私見も、理論的には争点主義が正当であると解している。その理由は、一般に争点主義の利点とされている諸点(参照、大野重国ほか『税務訴訟実務講座』ぎょうせい、164頁以下、司法研修所編『租税訴訟の審理について(改訂新版)』88頁以下等)のほか、被控訴人準備書面(9)26頁以下の論拠を重視しているからであるが、以下の点を若干補足しておきたい。

総額主義はそもそも賦課課税制度の前提の下で成り立つ議論であろう。賦課課税制度の下では、現在のドイツの申告がそうであるように、納税者が提出する申告はあくまでも課税処分の資料に過ぎず税額を算出する必要もなく、納税者が客観的に負っている納税義務額は課税庁が課税処分を通じて第一次的に決定するシステムである。このような制度の下では、訴訟においても総額主義的に運用するのは理解できないではない。しかし、わが国の現行所得税法や法人税法は申告納税制度を採用しており、納税者の申告を義務づけ、他方で、第一次的には当該申告を通じて税額を確定させるシステムを採用しており、課税庁は納税者の申告を通じて確定した税額に疑義がある場合には、調査を通じて具体的不適法な事由を確認し、青色更正の場合は当該理由を付記して更正する権限が付与されており、この場合においても納税者が申告によってすでに確定した税額そのものには影響がない(国税通則法29条参照)、とされている。従って、納税者が課税処分取消訴訟で争うのは自己の確定した税額を上

回る部分の税額の根拠となる事実と理由であって、処分の違法性一般でも、客観的納税義務額でもないはずだからである。

とはいえ、以下では総額主義を一応の前提としたうえで、理由差し替えの限界を検討しておきたい。

六 総額主義とその限界

総額主義という明文の根拠の欠いた一般論から、理由の差し替えが直ちに許されるものでないことは、何よりも最高裁自身が次のように述べていることから明らかである。

「そこで検討するに、原審が適法に確定したところによれば、(一)宅地の分譲販売等を業とする上告人は、本件係争事業年度において本件不動産を七六〇〇万九六〇〇円で取得しこれを七〇〇〇万円で販売したものとして、右事業年度の法人税につき青色申告書による確定申告をした、(二)これに対して、被上告人は、本件不動産の取得価額は六〇〇〇万円であるとして、他の理由とともにこれを更正の理由として更正通知書に附記し、本件更正処分をした、(三)ところが、被上告人は、本訴における本件更正処分の適否に関する新たな攻撃防禦方法として、仮に本件不動産の取得価額が七六〇〇万九六〇〇円であるとしても、その販売価額は九四五〇万円であるから、いずれにしても本件更正処分は適法であるとの趣旨の本件追加主張をした、というのであって、このような場合に被上告人に本件追加主張の提出を許しても、右更正処分を争うにつき被処分者たる上告人に格別の不利益を与えるものではないから、一般的に青色申告書による申告についてした更正処分の取消訴訟において更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張することができると解すべきかどうかはともかく、被上告人が本件追加主張を提出することは妨げないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。」(下線は筆者)(最高裁昭和56年7月14日判決、民集35巻5号901頁)。

この事案は、変更された理由が同一取引に関わる取得価格と販売価格にすぎず、当初の取得価格に関する攻撃防御の過程で販売価格についてもふれているのが通常であるので、納税者に「格別の不利益」を与えるものではないとされたにすぎず、理由差し替え一般について肯定することは躊躇しているのである。これは、最高裁自身が理由差し替えに対して課せられている以下のような現行法上の制約を意識しているからに他ならない。

(1) 明文の制約に反してはならない

まず、現行の税務訴訟の実務で総額主義的運営がなされているといっても、明文の根拠を欠いた総額主義を根拠に現行法が明文で要求している各種手続規制を無視することは許されない。従って、総額主義的運用が認められるとはいっても、それはあくまでも法が明文で要求している各種規制の枠内であり、それらの規制（もしくは納税者側の権利）との調和の上で認められるものであることに留意しなければならない。総額主義という明文根拠規定を欠いた一般論を根拠に、法が明文で要求しているものを否定もしくは無視しうるかのような理解がみられるが、租税法律主義が貫徹すべき租税法律関係においては基本的に誤った解釈方法であることに留意しなければならない。

なお、理由差し替えを肯定する根拠に、「理由の差し替えが必要になるのは、多くの場合上記帳簿書類の記載や説明が事実と相違することが後日判明した場合であり、かかる場合に差替えを許さないとすれば、不誠実な納税者を不当に利する結果となる」（参照、前掲・司法研修所編『租税訴訟の審理について（改訂新版）』128頁）ということが指摘されることがある。しかし、これは全く合理的な根拠とは言い難い。なぜなら、このことを強調するのであれば、「処分時や更正期間内に更正理由を見いだせないほど巧妙に事実を隠蔽したより悪質な納税者」を利している現行の各種手続規定そのものが不合理なものということになってしまうからである。わが国の税務行政はそのような一面的な租税正義ではなく、租税法律主義のもとで、納税者にも課税庁にも平等に各種義務を課し、租税正義及び公平課税の実現を図っていることを無視してはならないといえる。

現行税法が明文で課税庁に対して要求している規制のうち、総額主義的運営との関係で留意すべき問題は次の2点である。

(2) 理由付記規定は訓示規定ではない

まず、第1に現行法は青色申告者に対しては処分時に理由を付記することを命じている（法人税法130条2項）。この理由付記の趣旨は、最高裁昭和54年4月19日判決が明確に次のように述べているのは周知の通りであ。

「法が更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、法が青色申告

制度を採用して、青色申告にかかる所得の計算についてはそれが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものというべきである。」

つまり、理由付記の趣旨は、①処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制すること、②更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えること、にあるのである。

この理由付記については、かつて課税庁は明文規定が存在するにもかかわらず訓示規定に過ぎないと主張してきたが、最高裁昭和38年5月31日判決（民集17巻4号617頁）が「一般に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消を免かれないものといわなければならない」と明確にこれを否定した経緯があることにも留意すべきである。

このように、法が明文で理由付記を要求し、その欠如は課税処分の取消事由となる。理由の欠如は違法であるのに、理由差し替えが自由であるならば、処分時に処分理由を付記することを要求した同規定は全く法的に意味のない規定となり、訓示規定と実質は変わらないことになる。少なくとも、最高裁は同規定を課税手続の公正性を実現する重要な規定と位置づけているのであり、総額主義という実務運用を根拠に最高裁が確立した法理を形骸化することは許されないとわねばならない。その意味で、近年、総額主義が支配している実務においても、理由付記の趣旨を適切に受け止め始めている裁判例が出てきていることにも注目しなければならない。例えば、広島高裁松江支部平成5年6月30日判決（税務訴訟資料188号731頁）は「処分庁が原処分では全く問題にしていなかった課税要件事実（原処分の附記理由との間に基本的な課税要件事実の同一性を欠く事実）を訴訟の段階で初めて問題にし、これを処分理由として主張することは、右の理由附記制度の趣旨を全く否定するものとして許されないと解するのが相当である。その結果、真実の所得に応じた課税が制限されることがあるとしても、それは、刑事手続における真実発見の要請がデュープロセスの要請によって制限されることがあるのと同様、課税手続におけるデュープロセスの要請との調和

の観点からは是認されるべきであるといえるから、右結論を左右するものではない」とし、訴訟の段階になって初めて接待交際費をあげた課税庁の主張を退けた原審（松江地裁平成4年3月18日判決・税務訴訟資料188号731頁）の判断を支持している。理由付記が明文で要求されている現行法の解釈としては、このように解するのが妥当な解釈であり、総額主義という一般理論を振りかざして、課税手続におけるデュープロセスの要請を無視することは許されないと思われる。

なお、処分時における理由付記は現行法では青色申告者のみに要求されているが、青色申告者に対する処分以外の処分についても異議決定書においては理由を付記しなければならないとされている。青色申告者以外の者はこの異議決定書での理由を検討してその後さらに争訟を係属するか否かを検討することになり（同規定は最高裁昭和38年5月31日判決・民集最高裁判所民事判例集17巻4号617頁の趣旨を受けて昭和45年に導入された規定である。参照・志場喜徳郎『国税通則法精解』（第9版）816頁）、従って、異議決定を経た白色申告者については、基本的に青色申告者と同様に解して差し支えないと思われる。

（3）期間制限は除斥期間である

第2に、現行法は青色申告者・白色申告者を問わず、課税処分には一定の除斥期間を設けている。この制度は租税法律関係が長期間にわたって不確定な状況になることを避けるために時効ではなく、中断事由等のない除斥期間とされている。その反面、納税者にこの期間が経過すれば不利益な課税処分を受けるおそれなくなるという利益も与えていることになる。この除斥期間も総額主義的運用に対する重要な規制であり、納税者と課税庁双方平等適用されるべき手続規定である。

法が除斥期間を明文で定めているのに、総額主義を理由に経過後も理由の差し替えが認められるとなると、除斥期間の意義が失われることはいうまでもない。しかし、これを肯定する意見はその根拠として次のようなことを指摘している。「既に除斥期間内に課税処分がなされている以上、納税義務者の法的地位を早期に安定させようという除斥期間の趣旨は一応達成されているのであって、課税処分の適法性をめぐって現に訴訟で争っている場合にまで除斥期間の趣旨を拡大すべき必要性はないこと、処分理由の差替えを許しても、一定額の納税義務が課されている状態自体には何ら変動がなく、納税義務者にそれ以上の義務を新たに課するものではないこと、訴訟の

実際を見ても、除斥期間経過後に原告が新たな主張、立証を行ったために、税務署長が再調査をし、その結果処分理由の差替えを必要とする場合がしばしば見受けられるのであって、一方で原告の主張、立証を認めながら、税務署長に対してのみ、主張、立証を制限する根拠は除斥期間法定の趣旨からは説明できないこと、税務署長の主張が時機に遅れてなされた場合は、民訴法157条の規定を活用して適宜対処できる」(参照、前掲・司法研修所編『租税訴訟の審理について(改訂新版)』143頁)

しかし、これは実に奇妙な主張である。課税庁が甲という事実についてAという理由で更正処分をしてきたので、納税者が当該事実の有無や処分理由について相手側の立証を崩すために様々な角度から攻撃防御をするのは当然で、訴訟が係属している限り、現行法では「時機に遅れた攻撃防御」に該当する場合を除いて許されているのである。当初の処分理由を合理化する根拠であれば、除斥期間経過後といえども課税庁もさらなる主張をすることは当然許されていることに留意すべきである。前記の主張は、課税庁が除斥期間に服する以上、納税者も除斥期間以後は争う攻撃防御方法を変更してはならない、という前提があって成り立つ理論であり、その前提が誤っているのである。仮に、除斥期間後納税者が新たな主張をしたために当初の処分理由が維持しがたくなったのであれば、それは当初の処分理由に誤りがあっただけであり、そのようなことがないように処分庁の判断の慎重さを最高裁が求めていることを忘れてはならない。また、前記の主張は当初の課税処分に対する訴訟係属に一種の時効中断事由に類似した効果を付与している点でも除斥期間を採用した現行法の趣旨を形骸化させるものである。

(4) 期間制限は双方に平等に適用される

なお、このように主張すると、課税庁だけが期間制限に服することになり不公平であるという反論が示されうるので、このような期間制限の服するのは何も課税庁だけではない、ということも指摘しておこう。

例えば、納税者が申告後、増額更正処分を受けたので争っていたところ、当初の申告額が多すぎることが判明した場合、納税者は申告額を下回る税額を真の税額として更正処分の取消を求めうるのか、という問題について、わが国の判例は否定的である。当初の申告も増額更正に吸収されているならば、納税者の主張額まで取り消すこ

とも理論的には不可能ではなく、紛争の一回的解決をめざす総額主義からすればこのような主張を認めるほうがより適合的なはずであるが、判例はこの点になるとなぜか消極的である。例えば次の津地裁平成3年9月26日判決（税務訴訟資料186号598頁）のように更正の請求という制度で期間制限が設けられていることを主たる理由に、訴訟での主張を認めていない。「納税者が確定申告書を提出すれば、原則としてそれによって納税義務が確定するのであって（国税通則法16条）、納税者が確定申告書の記載の錯誤無効を主張しうる特段の事情の存する場合は別として、納税者が自己の申告にかかる所得金額が過大であるとしてその是正を求めようとするには所定期間内に更正の請求（国税通則法23条、法人税法82条）をなすことが要求されており、右手続を経由していないときは、税務署長による増額更正のうち申告額を超えない部分は納税者にとって不利益な処分であるということができず、その取消を求める訴えは訴えの利益を欠き不適法であるというべきである。」

結局、従来の実務は総額主義という一般論から、課税庁に対する期間制限は緩和し、逆に納税者に対する期間制限は厳守させるという不公平な扱いをしてきたといわざるを得ない。更正の請求の期間制限を厳格に守るべきなら、更正処分の期間制限も厳格に守るべきことは当然であり、法が明記している期間制限には原告被告双方とも平等に服すべきものであることが強調されねばならない。

（5）職権探知主義ではない

以上の明文の規制に加えて、税務訴訟においては職権主義的に解しうる規定があるものの、基本的には弁論主義に従うとされており、補充的にのみ職権主義的運用がなされるとされている（山田二郎・石倉文雄『税務訴訟の実務（改訂版）』新日本法規、平成5年、381頁）。その意味でわが国の税務訴訟は弁論主義をベースにしている審理方式であり、ドイツの税務訴訟のように職権探知主義を前提にする場合と同一の基準では考えられないといえよう。ドイツの場合も理由付記が要求されており（租税基本法121条）、処分理由を欠いていることは取消事由となるものの、他方で、財政裁判所での手続終了時までには補充することが認められ（租税基本法126条。2001年までは異議申立手続終了時までであった）、課税処分の理由が誤っていても、主文（Tenor）が他の理由で合法であるならば、裁判所独自に他の理由で適法化しうるかを審査し、請求を棄却できるとされている（三木「ドイツにおける税務訴訟の現実とその

背景(1)」民商法雑誌119巻4／5号633頁参照)。但し、この場合は課税庁にも訴訟費用を求めるようであるが、基本的には職権探知主義であることから理由の差し替え等については柔軟な対応をしているといえる。これに対して、弁論主義を基礎にしているわが国の場合には、当事者の主張がきわめて重要な意義を有しており、その意味で、同じ総額主義であるといってもその前提が異なることに留意しなければならない。

七 理由差し替え制限の類型

さて、以上のように、総額主義に対して現行法が課している各種規制を体系的に整理してみると、理由差し替えの可否を考える場合、類型化の基準となるのは(1)処分理由付記規定の有無、(2)除斥期間の徒過の有無に加えて、(3)処分の基礎となる事実の変更の有無、(4)処分理由もしくは根拠条文の変更の有無、であろう。このうち、(3)、と(4)の関係について、一般的には(3)事実関係の変更の方が問題あるように思われがちであるが、訴訟との関係ではむしろ(4)の変更の方が納税者にとってより酷になることに留意しなければならない。具体的に、Aという取引について給与所得という理由で課税された場合を想定してみよう。この場合、納税者はAという事実の有無もしくは給与所得の構成要件に該当しないことを争うことになる。ところが、結審間近になって、課税庁がBという事実に変更した場合には、Bの存在の有無、Bが給与所得に該当しないことを主張することになる。前提事実が変わるが、構成要件に関する反証等は基本的に従来のもので活かせる余地がある。これに対して、Aという事実を変えずに、給与所得ではなく一時所得だとの理由に変更した場合は、従来給与所得該当性をめぐって争っていた攻撃防御はすべて無駄となり、全面的に一時所得の構成要件問題に切り替えねばならなくなるので、その不利益はより著しいことに留意しておかねばならない。

また、(1)については、前述のように、白色申告の場合も不服申立段階で理由付記が明文で要求されており、訴訟段階の理由差し替えについては特に区別する必要はなくなっていると思われる。そうすると、(2)(3)(4)の要素を分解して類型化できるが、①除斥期間以内の事実の差し替え、②除斥期間内の根拠条文等の差し替え、③除斥期間内の双方の差し替え、④除斥期間後の事実の差し替え、⑤除斥期間後の根拠条文等の差し替え、⑥除斥期間後の双方の差し替え、の諸ケースに分けられるが、大きく類型化すると結局は次の2類型にまとめることになる。

【第1類型】この類型は、処分理由が明らかにされた後で（青色申告者の場合は処分時、それ以外の納税者の場合は異議決定時等）、訴訟で除斥期間内に処分理由が差し替えられるケースで、前記の①～③の諸ケースを含む類型である。この場合は、現行法の理由付記の規定に抵触するので、処分理由の差し替えは許されないことになるが、他方で除斥期間内であるので改めて更正処分をなしうることになる。青色申告者とそれ以外の場合との差異は、前者の場合は改めて処分するに際して明確に処分理由を特定しなければならないのに対して、後者の場合は異議決定までは理由を補強できるという差があるだけであろう。

【第2類型】これは、処分理由が明らかにされた（青色申告者の場合は処分時、それ以外の納税者の場合は異議決定時等）後で、かつ、除斥期間後に訴訟で理由が差し替えられる前記④～⑥のケースである。理由付記と除斥期間という二つの明文の規制に反し、しかも、弁論主義を基調とする審理方式において納税者の攻撃防御を著しく不利にすることも考慮すれば、この場合の理由の差し替えは厳格に許されないと解するのが相当であろう。根拠条文や事実関係等が「実質的に同一」ならば許される余地があるという議論もあるが、真に実質的に同一なら、当初の理由で争っても課税庁も困らないはずであるので、この議論はむしろ実質的な変更を認めてしまう議論であるといわざるをえない。

八 結論

以上のような前提で、本件の問題点を再度検討してみよう。

まず、本件の事実関係は次のように整理される。

①原告は平成7年12月27日に同年9月期の法人税の申告をした。

②被告は平成10年12月18日付で更正処分をした。原告が平成7年2月15日に行ったオランダ子会社の有利な第三者割り当て増資について、原告が新株引受人であるアスカファンド社から旧株の価値減少相当額255億円を受領しなかったのは、通常の経済人として不合理であるとの理由から、同族会社の行為否認規定（法人税法132条）を適用して更正処分を行ったわけである。

③そこで、原告がこれを争い、一定の審査請求手続を経て、平成12年3月24日に東京地裁に取消訴訟を提起した。原審において原告は被告の主張に反駁していたところ、平成13年7月30日に至って、被告が従来主張してきた同族会社の行為否認規定の適用を予備的主張に変え、主位的主張を「無償による資産の譲渡」（法人税法22条2項）に差し替えてきた。当初の申告期限から実に5年7ヶ月後、更正処分から2年7ヶ月後の理由の差し替えであった。

④次に、本件の場合、課税処分の基礎となった事実（課税要件該当事実とは異なる）は「原告がオランダ子会社の株主として特に有利な価額でアスカファンド社へ新株発行することにつき、無償で賛成した」ことであり、この事実関係は同一と思われる。従って、本件の理由差し替えは基礎事実及び根拠条文双方の差し替えではないが、基礎事実の差し替えではなく、根拠条文の差し替えであるという意味で、被控訴人の攻撃防御に多大な負担をかける変更であるといえる。

なお、控訴人は「法22条2項による課税の主張は、法132条による課税の主張に包含される関係にある」（控訴理由書58頁）といい、行為計算否認規定の中に法22条も包摂されるものであるように主張している。しかし、法人税法22条は法人の益金計算の原則規定であり、同族会社に特に向けられたものでも、特別な租税回避防止規定でもない。原則規定である以上すべての条文に関係するのは当然であり、そのことから132条に包含される関係にあるというのは少し強引な主張であろう。本件のような主張が許されるならば、あらゆる計算上の問題は結局22条の問題であり、いつでもこの条文に差し替えられることになり、妥当とはいえない。むしろ、両者はその構成要件が相当異なるものであり、法人税法132条の行為計算否認規定の場合、被控訴人は争点となっている行為が①通常の経済人として異常な行為形式であったか否か、②そして、通常の行為形式をとった場合と同様の経済的目的を達成したか否か、③当該異常な行為によって税負担が不当に減少したか否か、等の要件事実について攻撃防御をしなければならず、事実被控訴人はそのために膨大な時間と労力を費やしてきた。これに対して、法人税法22条2項の無償取引を根拠にされると、被控訴人は被控訴人とアスカファンド者間で無償の取引が行われたのか否か、あるいは法人間の実質上の贈与関係の有無等について攻撃防御しなければならず、従来行われてきた攻撃防御の大半は意味を失ってしまう。より具体的にいえば、前者の場合、課税庁は「原告がオランダ子会社の株主として特に有利な価額でアスカファンド社へ新株発

行することにつき、無償で賛成した」行為を法人税法の所得計算過程の対象になる取引ではない、即ち、法人税法22条2項も含めて法人税法の課税対象にならない、としたうえで、それを認めると法人税が不当に減少されるので、通常行われる取引行為に置き換えて課税したことになる。いわば課税対象となる行為がなかったが、そのまま認めると不当になるので、通常行われる取引を擬制していることになる。ところが、後者だと、当該行為が法人税法22条にいう「無償取引」そのものだということになり、全く逆の主張をすることになってしまう。このような理由の差し替えが許されたら、納税者がそれまで努力して主張してきたことの大半が水泡に帰してしまい、全面的に主張を再構成しなければならなくなる。したがって、本件は根拠条文が実質的に同一関係にあるとは到底いえないものであるし、差し替えが許されるものではないといわねばならない。